

1501362-85.2021.8.26.0079

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... tudo isso evidencia que a droga era destinada ao tráfico ilícito.

Ademais, como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

1ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501362-85.2021.8.26.0079 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501362-85.2021.8.26.0079

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2156284/2021 - DISE-

DEL.SEC.BOTUCATU, 18404745 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 27/21/219 - DISE-

DEL.SEC.BOTUCATU, 2156284 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

André Felipe Fim e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JÚNIOR.

Vistos.

ANDRE FELIPE FIM e LEONARDO SIQUEIRA DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados e viram-se processados como incurso nos artigos 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. art. 29, "caput", do Código Penal, e 35, "caput", da Lei 11.343/06, em concurso material, porque no dia 09 de junho de 2021, por volta das 16h30min, na Rua Mirabeau Camargo Pacheco, Conjunto Habitacional Clemente Jorge Roncari, nesta cidade e comarca de Botucatu-SP, agindo em concurso e com unidade de propósitos,

traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiras pessoas, 30 (trinta) porções de maconha, individualmente embaladas, com peso líquido de 27,81g, 460 (quatrocentas e sessenta) porções de cocaína em forma de crack, com peso líquido de 43,79g, e 146 (cento e quarenta e seis) porções de cocaína, com peso líquido de 7,19g, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 12), laudo de constatação provisória (fls. 34/40) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 120/122) acostados aos autos.

Consta ainda dos mesmos autos de inquérito policial que, na mesma época e local, os denunciados associaram-se para a prática do tráfico de drogas.

Segundo o apurado, os denunciados traziam consigo, guardavam e tinham em depósito entorpecentes, para entrega e consumo de terceiras pessoas, e eram associados, com permanência e estabilidade, para a mercancia de drogas.

Assim é que LEONARDO era o gerente do tráfico, responsável pela distribuição das drogas aos vendedores do condomínio, incumbindo a André realizar a venda das porções.

Na ocasião dos fatos, houve uma operação conjunta entre policiais civis e guardas municipais, visando coibir o tráfico de drogas no local dos fatos, conhecido ponto de intenso comércio ilícito de drogas.

Assim, os guardas municipais ingressaram no condomínio pela frente, enquanto os policiais civis permaneceram ao lado de fora, dando apoio.

Já no interior do condomínio, os guardas municipais surpreenderam André e outro indivíduo não identificado, em pleno ato de venda das porções de substância entorpecente. No local, também estava Leonardo, que atuava como gerente do comércio, supervisionando as vendas.

Ao avistarem os agentes policiais, André e o outro indivíduo empreenderam fuga, adentrando a um dos apartamentos. Ato contínuo, eles pularam a janela, oportunidade em que André foi abordado.

O indivíduo não identificado, no entanto, conseguiu fugir.

Assim que se deparou com os policiais, Leonardo também correu e conseguiu alcançar uma motocicleta, estacionada ao lado da quadra de esportes, com a qual empreendeu fuga.

Ao retornarem ao apartamento 14-B, Bloco 5, para onde André fugiu, os agentes policiais apreenderam uma pochete preta, dentro da qual havia diversos malotes de porções de entorpecentes, embalados e prontos para a distribuição, consistentes em trinta parangas de maconha, cento e quarenta e seis papelotes de cocaína e quatrocentos e trinta papelotes de cocaína em forma de crack, além de um rádio transmissor e a importância de R\$ 80,00 (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 12, laudo de constatação provisória de fls. 34/40, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 120/122 e laudo pericial de fls. 117/119).

Submetido à revista pessoal, foram localizados com André mais três malotes de cocaína em forma de crack, cada um contendo dez papelotes da substância, bem como um aparelho celular.

Diante desses fatos, os policiais prenderam André em flagrante.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado André confessou detalhadamente os

fatos, informando que já atuou no tráfico de drogas como “olheiro”, na biqueira onde Leonardo é o gerente, e que passou a ter a função de vender as porções (cf. fls. 05/06).

Por fim, André fez o reconhecimento de Leonardo como a pessoa responsável pelo gerenciamento da biqueira (cf. fls. 07).

Houve representação pela prisão temporária de Leonardo, que foi decretada (cf. fls. 78/82). Na oportunidade de seu cumprimento, sobreveio a apreensão de mais porções de drogas, de propriedade de Leonardo (fatos apurados em autos apartados), que por sua vez conseguiu fugir (cf. relatório de fls. 104).

Pela decisão de fls. 78/82 a prisão em flagrante de André Felipe Fim foi convertida em preventiva.

O indivíduo que realizava as vendas na companhia de André, não foi identificado (cf. relatório de fls. 47 e 126).

O relatório final foi apresentado em 30/06/2021 (fls. 129/132).

O Ministério Público ofereceu denúncia em 01/07/2021 (fls. 136/142) e requereu a decretação da prisão preventiva de Leonardo Siqueira dos Santos.

Por decisão de 02/07/2021 foi decretada a prisão preventiva de Leonardo Siqueira dos Santos e determinada a notificação dos réus (fls. 143/145).

O mandado de prisão preventiva expedido contra Leonardo foi cumprido em 10/05/2021 (fls. 95/97).

Os réus foram notificados (fls. 195 e 314).

Defesa preliminar em favor de André (fls. 227/229 ) e em favor de Leonardo (fls. 251/253).

A denúncia foi recebida em 05/10/2021, sendo designada audiência de instrução e julgamento (fls. 256).

Em cumprimento à decisão proferida no Habeas Corpus nº 207579, expediu-se alvará de soltura em favor de André, que foi cumprido em 22/10/2021 (fls. 275/277).

Os réus foram citados (fls. 314 e 316 ).

Durante a instrução criminal foram ouvidas três testemunhas arroladas pelo Ministério Público, seis testemunhas de defesa e os réu foram interrogados (mídia de fls. 341/342).

Em memoriais escritos, o Ministério Público pleiteou a condenação dos réus, como incursos nos artigos da denúncia, em concurso material (fls. 356/363).

A defesa de André afirmou que as provas, documentos e os depoimentos constantes dos autos não demonstram de forma inequívoca que o entorpecente encontrado pertencia ao acusado. Do mesmo modo, alega que não restou comprovada a associação dos réus para a prática do delito. Pugnou pela absolvição do réu e, subsidiariamente, pela aplicação da pena no mínimo legal (fls. 367/381).

A defesa de Leonardo também requereu a absolvição do réu no tocante aos crimes previsto nos artigos 33, “caput”, e 35, ambos da Lei 11.343/06, em razão da fragilidade probatória e da não comprovação da associação ou a aplicação da pena no mínimo legal (fls. 382/390).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade dos denunciados pela prática de condutas que, em tese, estariam a configurar os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos crimes descritos na denúncia restaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 01); o auto de exibição e apreensão (fls.12); o laudo de constatação (fls.34/40) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 120/122 ); o laudo pericial (fls. 16/17); o relatório (fls.129/132); os depoimentos das testemunhas, e a versão dos acusados.

Interrogado em juízo o réu Leonardo negou os fatos. Asseverou, em suma, que não conhece André. Que não estava no local na oportunidade dos fatos. Que apenas guardava em sua residência droga para pessoa conhecida como "Jacaré", pois passava por dificuldades financeiras (essência do depoimento de fls. 337/340).

O réu André também negou os fatos. Afirmou, em síntese, que não conhece Leonardo. Que estava no local apenas para consumir drogas, que não possui vínculo com o tráfico. Questionado sobre a sua versão apresentada em sede policial relatou que estava sem advogado e que não trouxe aquela versão que foi apresentada nos autos do inquérito policial (essência do depoimento de fls. 337/340).

O Dr. Paulo Fábio Buchignani, Delegado de Polícia, asseverou, em síntese, que havia investigação nos predinhos da CDHU, por ser ponto de tráfico. No dia em questão estavam em investigação quando receberam informações que Leonardo estaria chefiando o tráfico naquela região. Solicitaram apoio da Guarda. Os guardas entraram nos prédios. Os policiais civis ficaram de fora, na retaguarda. Leonardo conseguiu correr, pegar a motocicleta e fugir. Outros dois indivíduos foram vistos, um deles conseguiu fugir sem ser identificado. O outro era André, que foi detido. André confirmou a traficância. Confirmou que Leonardo era o responsável por organizar a distribuição das drogas. Havia associação entre os réus, com divisão de tarefas. Leonardo era o responsável por coordenar o tráfico e André vendia a droga distribuída (essência do depoimento de fls. 337/340).

A testemunha Alexandre Bazzo da Cunha, policial civil, ratificou as palavras do Delegado (essência do depoimento de fls. 337/340).

O GCM Fábio Rogério Marino corroborou a versão apresentada pelos policiais civis, afirmando, em resumo, que foram acionados pela Polícia Civil em razão de investigação de tráfico de drogas envolvendo o réu Leonardo. Os guardas entraram nos prédios enquanto os policiais civis ficaram fora, dando retaguarda. Dois indivíduos fugiram, um não identificado e outro Leonardo, o qual fugiu com sua motocicleta. O André foi detido. Foi encontrada considerável quantidade e diversidade de droga (fls. 337/340).

Por fim, as testemunhas de defesa, Patrícia Pereira, Paulo Santana, João Guilherme, Januário da Silva, Fernanda Pareira Fim e Geovanna Cauany Modesto Bicudo, declararam, em suma, que não presenciaram os fatos, alegando que os réus são usuários de entorpecente e que não sabem das suas relações com o tráfico (essência do depoimento de fls. 337/340).

Tem-se assim que os fatos imputados aos réus restaram satisfatoriamente comprovados. André foi preso em flagrante e, em solo policial, confessou os fatos com riqueza de detalhes, inclusive quanto à associação, tendo reconhecido Leonardo, por meio de fotografia, como sendo o chefe da traficância naquele local, deixando ainda clara a função de cada um na organização criminosa (fl. 07).

Todavia, em juízo André mudou sua versão sobre os fatos querendo fazer crer que é usuário de drogas e que estaria no local para consumir entorpecentes.

Anoto que não ficou provada nos autos nenhuma razão plausível para que o acusado André viesse em Juízo e modificasse sua versão sobre os fatos. Pelo contrário, ele foi ouvido em sede policial perante a autoridade policial da DISE de Botucatu, especializada no combate ao tráfico de drogas.

O corréu Leonardo, por sua vez, confessou parcialmente os fatos, afirmando que estaria guardando o entorpecente para uma pessoa de alcunha "Jacaré".

Em que pesem as versões dadas pelos acusados em juízo, o pedido acusatório merece ser julgado procedente. Vejamos:

Os agentes da lei, ouvidos em juízo, foram uníssomos no sentido de que havia denúncias de que Leonardo estaria chefiando o tráfico naquela região. Afirmaram que, na data dos fatos, estavam e operação no local, já conhecido pela venda de entorpecentes, momento em que visualizaram os réus e outro indivíduo não identificado, e que ao perceberem a presença da guarnição empreenderam fuga. Lograram prender André sendo localizada em sua posse considerável quantidade de entorpecente.

Embora o corréu Leonardo tenha fugido da abordagem, André foi detido em flagrante, confessando a traficância e apontando Leonardo como o responsável por organizar e distribuir as drogas, que eram vendidas por ele.

É certo que, ordinariamente, nossa sistemática penal atual não tem exigido a reiteração criminosa do tráfico de drogas, ou delito de mesmo gênero, para a configuração da infração penal prevista no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, pois o próprio teor deste dispositivo legal dispensa a persistência delitiva:

"Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 10, e 34 desta Lei:" (grifos aditados)

No entanto, para que não se confunda o mero concurso de pessoas de que trata o art. 29 do Código Penal com o delito de associação, estabeleceu-se o entendimento jurisprudencial e doutrinário que, para a caracterização do crime em comento, é imperioso o dolo dos agentes, que agiram em conluio, projete-se por mais de um fato criminoso, ou seja, que pretendam exercer a narcotraficância em caráter permanente, estável e duradouro.

Neste sentido, coleciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) 1. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei n.º11.343/2006. Precedentes. (...)" (STJ - HC: 214660 SP 62011/0178723-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2013).

Neste mesmo sentido, o seguinte julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"(...) Associação para o tráfico - Absolvição - Admissibilidade - O artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, não pode ser considerado um mero concurso de agentes, sendo necessário, para sua caracterização, a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de associar-se seja distinta da vontade da prática do crime visado (...)" (TJ-SP - APL: 00128516320108260344 SP0012851-63.2010.8.26.0344, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/04/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/04/2014)

Em idêntica lógica, assevera Guilherme de Souza Nucci que: "(...) Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico (...)" (Nucci, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume 1, Editora Revista dos Tribunais, 7ª ed, p. 337, item 103).

Assim, observando a premissa estabelecida e examinando o conjunto probatório amealhado nos autos, noto que, a quantidade, o modo de acondicionamento das drogas apreendidas, a nítida divisão de tarefas entre os réus (Leonardo era quem levava os entorpecentes todos os dias para o local, e André era o responsável pela venda aos usuários), as denúncias, bem como as condições em que se desenvolveram as ações criminosas, denotam que realmente os acusados estavam associados e vinham se dedicando à traficância em caráter permanente.

No mais, a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico de entorpecentes, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta do crime descrito no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

A versão dos Policiais e GCM's mostra-se de toda confiável no caso presente, mesmo porque os depoimentos foram firmes, coesos, e nitidamente imparciais.

Não bastasse isso, a quantidade de droga, as circunstâncias da prisão, a forma de acondicionamento, tudo isso evidencia que a droga era destinada ao tráfico ilícito.

Ademais, como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663).

Ainda:

"Não é dispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido". (RT 729/542).

"APELAÇÃO CRIMINAL DELITOS DOS ARTIGOS 12, "CAPUT", E 14, "CAPUT", DA LEI Nº 6.368/76- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas e a forma como estavam embaladas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Depoimentos dos policiais, em essência, seguros e coerentes, no sentido de que o réu estava envolvido na atividade ilícita. Existência de provas do caráter estável e duradouro da prática criminosa, bem caracterizando o delito do

artigo 14, "caput", da Lei nº 6.3686. Recurso não provido." (Apelação criminal n. 9000001-91.2005.8.260344, julgado em 10/03/2014, Des. Relator Luis Augusto de Sampaio Arruda).

A coerência do depoimento e o bom trabalho feito pelos policiais e GCM's deve ser prestigiados, compreendendo-se sobre a dificuldade cada vez maior na luta diária contra o crime, mormente contra o tráfico de drogas que está acabando com a nossa juventude e com suas famílias.

Diante da possibilidade da livre convicção motivada, lembremos que em se tratando de delitos clandestinos, a força dos indícios não pode ser desprezada. A respeito, vale anotar:

"PROVA INDICIÁRIA - FORÇA PROBANTE - NO QUE INTERESSA AO DIREITO PROCESSUAL, A FORÇA PROBANTE DOS INDÍCIOS É IGUAL À DE QUALQUER OUTRO MEIO DE PROVA - SE O ESPÍRITO HUMANO, NA MAIORIA DAS VEZES, NÃO ATINGE A VERDADE SENÃO POR ARGUMENTOS PROBATÓRIOS INDIRETOS, PARA EVIDENCIAR A CIRCUNSTÂNCIA IGNORADA COM O NEXO DE CAUSALIDADE, OU DE IDENTIDADE ESPECÍFICA, NÃO PODERIA, POIS, SER DESPREZADA, NOS JUÍZOS CRIMINAIS, A PROVA INDICIÁRIA, DÊS QUE CADA VEZ MAIS A INTELIGÊNCIA, A PRUDÊNCIA E A CAUTELA DOS CRIMINOSOS DIFICULTAM A PROVA DIRETA" (RT 728/478).

A matéria, aliás, dispensa maiores considerações, sendo hipótese de traficância.

O Juiz de Direito, analisando a questão no contexto, observada a livre convicção motivada, deve decidir segundo sua consciência, buscando o alcance das verdadeiras finalidades das Leis.

Nesse diapasão:

"PERANTE O NOVO DIREITO BRASILEIRO, O JUIZ CRIMINAL É CHAMADO A EXERCER O SEU NOBRE OFÍCIO COM A SUA PRÓPRIA CONSCIÊNCIA, COM SEU PRÓPRIO RACIOCÍNIO, COM SUA LIVRE CRÍTICA. JÁ NÃO SERÁ UM INTÉRPRETE ESCOLÁSTICO DA LEI, UM APLICADOR DE JUSTIÇA TARIFADA, UM ÓRGÃO AUTOMÁTICO DE FÓRMULAS SACRAMENTAIS, MAS UMA CONSCIÊNCIA LEVRE A REGULAR DESTINOS HUMANOS" (TACRIM-SP - Rel. VALENTIN SILVA - RT501/307).

Não bastasse, o laudo de fls. (120/122) resultou positivo para cocaína, cocaína na forma de "crack" e Cannabis sativa L (maconha).

Sendo assim não resta dúvidas de que no dia, local e horário indicados na exordial, os réus agindo em concurso e com unidade de propósitos, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito drogas, para fins de entrega ao consumo de terceiras pessoas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como se associaram para fins de praticar a traficância.

As condutas encontram tipicidade na exata correspondência com os delitos definidos nos artigos 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. art. 29, "caput", do Código Penal, e 35, "caput", da Lei 11.343/06, em concurso material.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade dos denunciados ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência dos delitos e passo a aplicar as penas.

DO RÉU LEONARDO SIQUEIRA DOS SANTOS.

A) Do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06:

O acusado é primário (fls. 177/178). Contudo, atento ao que estabelece o artigo 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei 11.343/06, os motivos, as circunstâncias, a culpabilidade de elevada intensidade decorrente da quantidade, variedade e

potencialidade dos entorpecentes (30 porções de maconha, com peso líquido de 27,81g, 460 porções de cocaína em forma de crack, com peso líquido de 43,79g, e 146 porções de cocaína, com peso líquido de 7,19g,), quantidade essa suficiente para razoável disseminação, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor mínimo legal.

Diminuo a pena em 1/6 tendo em vista a menoridade relativa do acusado, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Não se vislumbra agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena a serem consideradas.

O réu não faz jus ao disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, pois a grande quantidade, diversidade e potencialidade dos entorpecente demonstram, bem como as denúncias dando conta que o acusado era o "chefe" do tráfico no local dos fatos, por si só, o grau de envolvimento com o tráfico e que não se trata de "marinheiro de primeira viagem". Assim, o réu não pode ser tratado igual aos traficantes neófitos, que tem ao seu favor a causa de diminuição de pena acima mencionada. Entender de forma contrária seria no mínimo ferir o princípio da isonomia, e dar um tratamento benéfico àqueles que traficam em larga escala, algo não pretendido pela Lei 11.343/06.

Nos termos do referido dispositivo legal, entendo que o magistrado poderá reduzir a pena fixada ao agente – de um sexto a dois terços – desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Cuida-se, pois, de faculdade que o Juiz de Direito usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado. Na aplicação do preceito o Juiz deve verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena. E, na hipótese vertente, repito, tendo em vista as circunstâncias que envolveram a prisão dos réus, não há dúvidas de que se dedicavam ao comércio ilícito de entorpecente e, portanto, ostentam periculosidade maior. Assim, inviável a diminuição de pena supramencionada.

Nesse diapasão, cumpre trazer à baila recente acórdão prolatado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em autos sentenciados por este magistrado, assim ementado:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. PENA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, ANTE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231, DO STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

1. A remissão feita pelo Magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (AI 825.520 AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 31.05.2011; AI 814.640/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02.12.2010; HC 92.020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 21.09.2010; HC 101.911/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27.04.2010; HC 100.221/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04.05.2010; HC 94.384/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02.03.2010; Emb. Decl. MS 25.936-1/DF, Rel. Min. Celso



de Mello, j. 13.06.2007; HC 98.814/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 23.06.2009; HC 94.243/SP, Rel. Min. Eros Grau, j. 31.03.2009; HC 96.517/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03.02.2009; RE 360.037/SC, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 07.08.2007; HC 75.385/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 07.10.1997).

2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada na posse do réu.

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 1ª Câmara Criminal Extraordinária Voto n. 3.999 - Apelação n. 0006177-49.2014.8.26.0079 3 civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10).

Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.05.14; RHC 45.173/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.05.14; HC 109.105/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23.02.10).

4. Pena mantida conforme fixada na Origem.

5. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal ante o reconhecimento de circunstâncias atenuantes. Entendimento da Súmula n. 231, do STJ.

6. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF.

7. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.

8. Improvimento do recurso defensivo." (TJ/SP, Apelação Criminal n. 0006177-49.2014.8.26.0079, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Des. Relator Airton Vieira, julgado em 03 de fevereiro de 2016, grifei).

B) Do delito previsto no artigo 35, "caput", da Lei 11.343/06:

O acusado é primário (fls. 177/178). Por conseguinte, as circunstâncias indicadas no artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis. Fixo, pois, a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Deixo de considerar a atenuante da menoridade relativa uma vez que a pena-base já fora fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Não se vislumbram agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena a serem consideradas.

Por força do concurso material de crimes, artigo 69 do Código Penal, as penas dos delitos de tráfico e associação para o tráfico devem ser somadas, pois foram duas condutas delitivas praticadas pelo réu no mesmo contexto. Assim, fixo as penas em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 1.283 (mil, duzentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo valor legal.

A pena restritiva de liberdade será cumprida em regime inicialmente fechado, consoante art. 2º., §1º., da Lei nº. 8.072/90, na redação dada pela Lei nº. 11.464/2007.

Torno definitiva a pena em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.283 (mil, duzentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo valor legal.

DO RÉU ANDRÉ FELIPE FIM.

A) Do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06:

O acusado é primário (fls. 162/165). Contudo, atento ao que estabelece o artigo 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei 11.343/06, os motivos, as circunstâncias, a culpabilidade de elevada intensidade decorrente da quantidade, diversidade e potencialidade dos entorpecentes (30 porções de maconha, com peso líquido de 27,81g, 460 porções de cocaína em forma de "crack", com peso líquido de 43,79g, e 146 porções de cocaína, com peso líquido de 7,19g,), quantidade essa suficiente para razoável disseminação, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor mínimo legal.

Diminuo a pena em 1/6 tendo em vista a menoridade relativa do acusado, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Não se vislumbram agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena a serem consideradas.

O réu não faz jus ao disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, pois a grande quantidade, diversidade e potencialidade dos entorpecente, bem como sua passagem pela Vara da Infância e Juventude (fls.162) demonstram, por si só, o grau de envolvimento com a criminalidade e que não se trata de "marinheiro de primeira viagem". Assim, o réu não pode ser tratado igual aos traficantes neófitos, que tem ao seu favor a causa de diminuição de pena acima mencionada. Entender de forma contrária seria no mínimo ferir o princípio da isonomia, e dar um tratamento benéfico àqueles que traficam em larga escala, algo não pretendido pela Lei 11.343/06.

Nos termos do referido dispositivo legal, entendo que o magistrado poderá reduzir a pena fixada ao agente - de um sexto a dois terços - desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem

integre organização criminosa.

Cuida-se, pois, de faculdade que o Juiz de Direito usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado. Na aplicação do preceito o Juiz deve verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena. E, na hipótese vertente, repito, tendo em vista as circunstâncias que envolveram a prisão dos réus, não há dúvidas de que se dedicavam ao comércio ilícito de entorpecente e, portanto, ostentam periculosidade maior. Assim, inviável a diminuição de pena supramencionada.

Nesse diapasão, cumpre trazer à baila recente acórdão prolatado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em autos sentenciados por este magistrado, assim ementado:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. PENA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, ANTE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231, DO STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

1. A remissão feita pelo Magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Precedentes do STF (AI 825.520 AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 31.05.2011; AI 814.640/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02.12.2010; HC 92.020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 21.09.2010; HC 101.911/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27.04.2010; HC 100.221/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04.05.2010; HC 94.384/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02.03.2010; Emb. Decl. MS 25.936-1/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.06.2007; HC 98.814/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 23.06.2009; HC 94.243/SP, Rel. Min. Eros Grau, j. 31.03.2009; HC 96.517/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03.02.2009; RE 360.037/SC, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 07.08.2007; HC 75.385/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 07.10.1997).

2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada na posse do réu.

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 1ª Câmara Criminal Extraordinária Voto n. 3.999 - Apelação n. 0006177-49.2014.8.26.0079 3 civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min.

Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10).

Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.05.14; RHC 45.173/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.05.14; HC 109.105/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23.02.10).

4. Pena mantida conforme fixada na Origem.

5. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal ante o reconhecimento de circunstâncias atenuantes. Entendimento da Súmula n. 231, do STJ.

6. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF.

7. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.

8. Improvimento do recurso defensivo." (TJ/SP, Apelação Criminal n. 0006177-49.2014.8.26.0079, 1ª Câmara Criminal Extradinária, Des. Relator Airton Vieira, julgado em 03 de fevereiro de 2016, grifei).

"TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras seguras dos policiais que efetuaram as diligências.

DESCCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USUÁRIO. Impossibilidade. A noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização. PENA. DIMINUIÇÃO. ARTIGO 33, PARÁGRAFO 4º DA LEI Nº

11.343/06. Impossibilidade. Prova toda no sentido de que o réu se dedica a atividade criminosa desde a sua adolescência. RECURSO DESPROVIDO (Apelação criminal nº 990.09.031867-8, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Machado de Andrade, v.u., 18.06.2009).

B) Do delito previsto no artigo 35, "caput", da Lei 11.343/06:

O acusado é primário (fls. 162/165). Por conseguinte, as circunstâncias indicadas no artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis. Fixo, pois, a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Deixo de considerar a atenuante da menoridade relativa uma vez que a pena-base já fora fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Não se vislumbram agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena a serem consideradas.

Por força do concurso material de crimes, artigo 69 do Código Penal, as penas dos delitos de tráfico e associação para o tráfico devem ser somadas, pois foram duas condutas delitivas praticadas pelo réu no mesmo contexto. Assim, fixo as penas em

08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 1.283 (mil, duzentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo valor legal.

A pena restritiva de liberdade será cumprida em regime inicialmente fechado, consoante art. 2º., §1º., da Lei nº. 8.072/90, na redação dada pela Lei nº. 11.464/2007.

Torno definitiva a pena em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.283 (mil, duzentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo valor legal.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR ANDRÉ FELIPE FIM e LEONARDO SIQUEIRA DOS SANTOS, cada um, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.283 (mil, duzentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo valor legal, ambos por infração aos artigos 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. art. 29, "caput", do Código Penal, e 35, "caput", da Lei 11.343/06, em concurso material.

Decreto o perdimento do numerário e objetos apreendidos (fl. 12), na forma do artigo 63 da Lei nº. 11.343/06, pois vinculados à prática do comércio ilícito, não havendo qualquer prova em contrário. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Caso algum dos bens apreendidos não possua valor comercial, deixo de decretar o seu perdimento e autorizo a sua DESTRUIÇÃO, nos termos dos artigos 25 a 28, da Portaria SENAD nº 01, de 10/01/2020. Expeça-se o necessário, oportunamente.

O réu, ANDRÉ FELIPE FIM se insatisfeito com a decisão poderá recorrer em liberdade.

O réu LEONARDO SIQUEIRA DOS SANTOS se insatisfeito com a decisão, não poderá recorrer em liberdade. Recomende-se o réu na unidade prisional em que ele se encontra.

Em que pese o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736/12, deixo de aplicar a detração no presente caso porque os sentenciados, por serem primários, não cumpriram o lapso temporal necessário para a progressão de regime. A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, ou seja, em relação apenas ao início de cumprimento da pena, de modo que se este não for alterado, não pode haver cálculos para diminuir a reprimenda, sob pena de se interferir na competência do Juízo da Execução Penal. Assim, no presente caso, o regime de cumprimento de pena não será alterado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

Anoto a recente decisão prolatada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar recurso de sentença proferida por este magistrado:

"Incêndio qualificado - Confissão judicial - intenção de causar incêndio bem comprovada - Fogo em casa habitada, com exposição dos vizinhos e demais moradias a perigo - Palavras da vítima e policiais - Responsabilidade comprovada - Dolo caracterizado - Condenação mantida; Incêndio qualificado - Progressão de regime - Aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal - Benefício exige o cumprimento de condições objetivas e subjetivas - Questão a ser aferida pelo juízo das execuções - Exegese do art. 66, inciso III, "c", da Lei nº 7.210/84 - Recurso improvido". (Apelação criminal n. 3004354-23.2013, 4ª Câmara de Direito Criminal, Des. Relator Alexandre Almeida, julgado em 27 de abril de 2016).

Expeça(m)-se certidão(ões) de honorários ao(s) defensor(es) dativo(s), conforme Convênio Defensoria/OAB, se o caso.

Transitada esta em julgado, lancem os nomes dos réus no rol dos culpados.

Por fim, nos termos do Provimento CSM nº 2482/2018 (DJE 24/10/2018, p. 02/03) e artigo 525 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça, defiro a incineração das amostras guardadas para contraprova. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Botucatu, 27 de abril de 2022.

Josias Martins de Almeida Júnior  
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA